Le contrat

Les fondamentaux contractuels

Philippe NICOLAS

05/02/2026

1- Le contrat – Formation

- Le contrat est défini **à l'art. 1101** du Code civil de la façon suivante *: « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations »*
- **Le principe fondateur** de la notion de contrat est citée à l'art. 1103 du Code civil : ***« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait »***
- L'approche de la réalité du contrat **nécessite de qualifier les différentes et principales réalités contractuelles afin de pouvoir en déterminer le régime juridique qui est applicable**
- A l'occasion de la réforme du droit commun des contrats par **l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016**, plusieurs distinctions nouvelles sont apparues et certaines de celles qui existaient déjà, **ont évolué dans leur portée**
- Ainsi les contrats consensuels, solennels et réels, et les contrats de gré à gré (ou négocié) ou **d'adhésion constituent une première source de classification selon le mode de conclusion du contrat (I)**
- Une seconde source de classification est constituée **selon l'effet du contrat (II)**
- Une troisième source de classification peut être **distinguée en fonction de la réglementation qui est applicable au contrat (III)**
- Enfin une quatrième et dernière classification peut être **opérée selon la durée du contrat (IV)**

Le contrat : La classification selon le mode de conclusion : Contrats consensuels, solennels, réels

- **Le contrat consensuel** : Un contrat consensuel est un contrat qui se conclut par **le seul échange des consentements** « quel qu'en soit le mode d'expression » (C. civ., art.1109 al.1). **C'est la règle qui dérive du principe du consensualisme**
- **Le contrat solennel** : Un contrat est dit solennel **lorsque le consentement ne peut être exprimé, à peine de nullité**, ***« que selon certaines formes déterminées par la loi »***. Il semble ainsi qu'il soit possible pour les parties de solenniser un contrat consensuel en soumettant, soit d'un commun accord, soit en vertu d'une obligation objective, sa validité à l'accomplissement d'une formalité que le législateur impose
- **L'acte d'avocat ou « acte contresigné par avocat** » constitue en outre (Cf loi de modernisation des professions judiciaires n° 2011-331 du 28 mars 2011 et introduit par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 à l'art.1374 du C. civ.) une des **voies de modernisation de la contractualisation de certains actes juridiques**. Dans ce cadre l'article 229 du C.civ. énonce que : ***«… les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce, par acte sous signature privée, contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d'un notaire ».*** En outre l'acte d'avocat a un second effet, outre celui du rappel de la portée de l'acte conclu, qui réside dans le renversement de la charge de la preuve en matière de contestation de signature (c'est à celui qui conteste avoir signé l'acte contresigné par avocat de prouver sa bonne foi)
- **Un contrat réel** : Le contrat réel **est un contrat qui ne se forme que par la remise de la chose qui est l'objet de la prestation** (C. civ., art. 1109, al. 3) (ex : contrat de prêt, de gage, de dépôt…)

Le contrat : La classification selon le mode de conclusion : Contrats négociés et contrats d'adhésion

- Le modèle contractuel du Code Napoléon est le **contrat négocié** ou encore **le contrat de gré à gré**. Dénommé comme tel du fait de la bilatéralité de sa formation dans la mesure ou le pouvoir unilatéral d'une des parties ne trouvait pas sa place dans cette forme de contrat. La formation de ce **contrat était le fruit d'une discussion entre les parties (règle du consensualisme)**.
- Cette conception de formation du contrat fondée sur **la fiction de l'égalité des contractants était largement illusoire**. **Egaux en droit, les parties ne le sont pas nécessairement en fait**, l'un pouvant se retrouver soumis à l'autre, notamment en raison d'un déséquilibre de puissance économique. Ce sont ces développements qui ont permis de faire apparaître la notion plus tardive de contrat d'adhésion.
- **Le contrat d'adhésion est une forme de contrat** ***: « … qui comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l'avance par l'une des parties ».***
- Son régime est précisé par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 après n'avoir longtemps été qu'une **invention jurisprudentielle**, la Haute Cour précisant ***« …aucune disposition légale ne prohibe d'une façon générale l'insertion de clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité dans les contrats d'adhésion (Civ. 1ere, 19 janv. 1982, Bull. civ. I, n° 29)***
- Les clauses non négociables, soustraites à la négociation, sont couramment dénommées **« conditions générales »,** et doivent être, pour être opposables : ***« déterminées à l'avance par l'une des parties »***
- Attention, en principe un contrat ne peut être qualifié de contrat d'adhésion que s'il comporte des **« conditions générales »,** et si ces dernières ont été rédigées par un des contractants

Le contrat : La classification selon le mode de conclusion : Contrats négociés et contrats d'adhésion

- La jurisprudence a certes accordé une certaine protection à la partie en situation de faiblesse en subordonnant, par exemple, **l'efficacité des clauses du contrat d'adhésion** a la possibilité effective d'en avoir pris connaissance avant la conclusion du contrat résultant du principe : ***« un contractant qui avait accepté ce qu'il n'était pas libre, en fait, de refuser, ne pouvait aller jusqu'à soutenir qu'il avait accepté ce qu'il ignorait… »*** **sous l'appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 1ere, 19 déc. 1979, Bull. civ. I, n°330**
- L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a consacré à l'article 1110 du Code civil, ces deux monuments de la formation du contrat en énonçant les définitions suivantes :
- **Le contrat de gré à gré par rapport au contrat d'adhésion** *: « …est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties, alors que le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l'avance par l'une des parties »*

Le contrat : La classification selon l'effet du contrat : Contrats synallagmatique et unilatéraux (II)

- Le contrat est dit **synallagmatique** : ***« lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres »***
- Ainsi le contrat synallagmatique **résulte de la réciprocité des contreparties** que les cocontractants doivent fournir
- Le contrat est dit **unilatéral** *: **« lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci »***
- La distinction entre les deux catégories de contrats trouve son intérêt d'abord sur le plan du formalisme, conclusion d'un double original pour le contrat synallagmatique alors qu'un simple original (pouvant être reproduit) suffit pour le contrat unilatéral.
- **Autre point d'intérêt**, certains des remèdes à l'inexécution ne peuvent être envisagés que dans des contrats synallagmatiques, à l'exclusion des contrats unilatéraux
- Comment ***« l'exception d'inexécution »*** et la ***« résolution judiciaire »*** du contrat peuvent elles être envisagées si les parties ne se sont pas obligées réciproquement et donc si elles ne se ***« tiennent »*** pas mutuellement ?

Le contrat : La classification selon l'effet du contrat : Contrats à titre onéreux et à titre gratuit (II)

- La définition citée à l'article 1107 du Code civil évoque **le contrat à titre onéreux** comme suit *: « **Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure** »*
- Mais en ce cas quelle est la différence d'avec un contrat synallagmatique ? Dans les faits il faut se placer sur **le terrain de l'intention des parties de recevoir ou non, un avantage de l'autre, en contrepartie de celui qu'elle procure**
- Le contrat à **titre gratuit** est défini comme suit : ***« Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre, ni recevoir de contrepartie »***. Là encore c'est l'intention des parties qui caractérise la réalité de la situation

Le contrat : La classification selon l'effet du contrat : Contrats commutatifs et aléatoires (II)

- En vertu de l'article 1108, al.1 du Code civil le **contrat commutatif** est celui dans *lequel* ***« chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit »***
- Ainsi dans le contrat commutatif chacune des parties connaît, au moment de s'engager, la contrepartie qu'elle recevra en échange de celle qu'elle fournit. Les contreparties sont donc définitivement fixées, dés l'origine, dans leur existence et dans leur étendue. Il importe peu toutefois que la prestation reçue soit équivalente à celle qui est fournie, il suffit qu'elle soit regardée comme telle. Il s'agit donc d'une équivalence subjective.
- Le contrat ***« est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre, les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes attendues, d'un événement incertain »***
- Il faut noter toutefois que dans un contrat aléatoire l'incertitude doit être partagée par toutes les parties au contrat même si matériellement cette incertitude peut n'affecter que l'avantage d'une des parties dans son existence ou dans son étendue
- On peut aussi dire qu'un **contrat est aléatoire** ***« lorsque l'avantage que les parties en retireront, n'est pas appréciable lors de la formation du contrat parce qu'il dépend d'un événement incertain »*** *(Com. 10 janv. 1960 cité par BENABENT)*

La classification selon l'effet du contrat : Contrats-échange, contrats-organisation (II)

- Le modèle contractuel dominant est **le contrat-échange** pour qui la fonction d'échange économique constitue l'un des traits dominants, souvent caractérisé de la façon suivante : ***« les contrats qui ont pour objet une permutation au terme de laquelle le bien de A se trouve entre les mains de B et le bien de B de bien entre les mains de A ».*** **Le contrat de vente commerciale qui avait servi de modèle aux rédacteurs du Code Napoléon, est le prototype de cette catégorie**
- Aux côtés du modèle dominant d'autres contrats, aux finalités distinctes, existent où l'objet est la mise en commun et l'alliance entre des parties distinctes plutôt que l'échange de biens physiques
- Le contrat est par essence un acte créateur d'effets juridiques obligatoires caractéristique qui peut parfaitement trouver à s'illustrer dans le cadre d'accords de volonté productifs d'effets juridiques obligatoires, et où le trait dominant ne serait pas le contenu du contrat mais l'accord de volontés qu'il suppose.
- Ainsi à côté du contrat-échange existe un modèle de type contrat de société dénommé sur le plan de la caractérisation comme un **contrat organisation** qui ***« institue une coopération entre A et B lesquels mettent en commun des choses qui jusque là leur étaient propres et les emploient à une activité conjointe »***
- Le contrat organisation peut se caractériser ainsi par la mise en place : ***« d'organes […] chargés d'assurer et de garantir la réalisation de [l'objet du contrat] selon des modes de répartition des missions et des pouvoirs qui varient selon le type d'organisation (DIDIER, Brèves, note sur le contrat organisation, in L'avenir du Droit ; mélanges en hommage à François TERRE, 1999 Dalloz, p. 635 s., à p. 638)***

La classification selon l'effet du contrat : Contrats-partage ; contrat-alliance ; contrat-concentration et coopération (II)

- Dans sa version élargie le contrat-organisation peut également déboucher sur le contrat-partage défini comme étant conclu en vue de la finalité suivante : ***« la réalisation d'une distribution c'est-à-dire d'un partage de valeurs, comme dans une société, un mariage ou encore l'association »***
- Dans un contrat partage les parties sont mues, à l'opposé de l'affrontement, par un désir de collaboration.
- Cette configuration de création d'obligations respectives dans cette intention, sont également dénommées **« contrat-alliance »** ou encore de **« contrat-concentration »** du fait de l'unification des volontés qui s'exprime dans ce cadre
- Ces figures sont parfois également qualifiées de « **contrat-coopération** » dont le critère distinctif tient en ***« une mise en relation d'actifs complémentaires dans le cadre d'un projet commun mettant ainsi en scène des intérêts économiques convergents mais différents »***
- Le contrat-coopération présente des traits hybrides communs à plusieurs types de démarches tels : les contrats d'édition, de franchise, ou encore de consortium. Ce type de contrat tisse entre les obligations des parties un lien de complémentarité ordonnancée formant ainsi une chaîne d'obligations instrumentales et finales de manière à lier les intérêts convergents mais différents des parties
- Ces démarches mettent d'abord en valeur la diversification des modèles contractuels qui s'est développée dans la période récente où la bonne foi (C. civ., art. 1104) constitue souvent le critère dominant

La classification selon la réglementation applicable : Contrats nommés et innomés (III)

- Il est fait mention de cette distinction classement à l'art. 1105 du Code civil : ***« les contrats qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales qui sont l'objet du présent sous –titre »***
- **Les contrats nommés** sont ceux qui ont reçu du législateur, non seulement une dénomination propre, mais également un régime spécifique qui complète ou qui déroge partiellement au droit commun tels le **contrat de vente**, de louage ou encore de mandat ou encore les **contrats cadre** prévus à l'article 1111 du Code civil.
- A l'opposé les **contrats innommés** sont ceux que la loi ne réglemente pas sous une dénomination propre
- Cette définition légaliste doit être complétée parce que trop restrictive, certains auteurs considèrent qu'il conviendrait de considérer les contrats nommés, comme des **contrats dont le régime juridique est défini**, cette définition pouvant être le fait soit de la loi, de la jurisprudence ou encore de la pratique
- La distinction entre les deux demeure fluctuante et relative, d'abord parce que la loi peut évoluer et **« nommer »** un type de contrat qui ne l'était auparavant pas. Relative, ensuite parce que le législateur peut se saisir d'un contrat innommé (par la loi), que pour régir certains aspect de son régime propre (cas du contrat de sous-traitance par exemple)
- Dans ce dernier cas, le contrat quoique reconnu par la loi n'est alors que partiellement réglementé, c'est le cas du contrat de crédit-bail
- La distinction et son intérêt entre ces deux types de contrats **réside d'abord dans le niveau de protection offert en cas de litige. Finalement le cadre déterminé par la loi permet de laisser libre cours à l'imagination des parties**

La classification selon la réglementation applicable : Contrats internes et internationaux (III)

- En droit international privé : ***« Un contrat peut être qualifié de « contrat international », par opposition à un « contrat interne », lorsqu'il existe un ou plusieurs éléments d'extranéité susceptibles de rattacher le contrat en question à différents ordres juridiques (déf. Doyen BATTIFOL) »***
- Autre définition, plus économique et monétaire *: **« Un contrat est international lorsqu'il implique un flux et un reflux [de valeurs] au dessus des frontières(Civ. 17 mai 1927, DP 1928, 1.25, concl. Matter, note Capitant) ou encore de manière plus compréhensive lorsqu'il met en jeu les intérêts du commerce international »***
- Dans cette situation la question de compétence de l'ordre juridique pour régir le contrat est souvent difficile à trancher : plusieurs points sont à prendre en compte : Les juridictions d'un Etat ne sont pas nécessairement amenées à trancher les questions qui leur sont soumises par application du droit interne. Le droit international privé est en effet la branche du droit privé chargé d'identifier les règles de conflit permettant de désigner la loi applicable à un litige donné.
- En matière contractuelle, les règles de conflit ont fait l'objet d'une unification dans le cadre de l'Union européenne par le biais de la convention de Rome du 19 juin 1980, aujourd'hui remplacée par le règlement Rome I du 17 juin 2008 (Règl. n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles)
- **En application de ces prescriptions** : Les contractants peuvent ainsi désigner la loi de n'importe quel Etat, y compris la loi d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne, et peuvent pratiquer le **« dépeçage »** du contrat, c'est-à-dire découper le contrat afin de voir appliquer des lois distinctes à chaque partie du contrat
- A défaut de choix, le Règlement prévoit des rattachements objectifs en fonction des types de contrats

La classification selon la réglementation applicable : Contrats internes et internationaux (III)

- Par exemple, la loi applicable à **une vente de biens sera la loi du lieu de résidence du vendeur** (Régl.. du 17 juin 2008, art. 4.1(a))
- Lorsque le **type de contrat n'est pas envisagé par le Règlement**, c'est alors la loi du lieu de résidence de la partie qui doit fournir la prestation caractéristique qui doit s'appliquer (art. 4.2(a))
- Il existe enfin une clause d'exception qui permet au juge, lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un Etat autre que celui de la loi choisie par les parties, ou désignée par les rattachements objectifs, d'appliquer la loi de cet Etat (Régl. du 17 juin 2008, art. 4.3)
- Les droits internes n'étant pas légitime pour réglementer les contrats internationaux (la loi interne ne peut pas saisir le contrat dans sa dimension internationale) des conventions ont été élaborées, à l'échelle internationale, pour harmoniser, non pas seulement les règles de conflit, mais également le droit matériel applicable aux conventions en question.
- La plus reconnue est la **convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980**. Au-delà ont été également mis au point les principes Unidroit relatifs aux contrats du commerce international. Le constat de l'insuffisance de la convention de Rome sur la loi applicable au contrat, et de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises ont débouché sur l'élaboration des Principes du droit européen des contrats
- Toutefois ces corps de règles ne peuvent pas être choisis par les parties, au moins lorsque leur litige est soumis à une juridiction étatique. Le Règlement de Rome I refuse en effet le ***« contrat sans loi »,*** ou encore la désignation par les parties ***« d'une loi sans Etat »,*** les évolutions sur ce point critique paraissent difficiles malgré les enjeux

La classification selon la durée du contrat : Contrats à exécution successive et instantanée (IV)

- C'est la doctrine qui ensuite du Code Napoléon à conçu cette différenciation laquelle peut être évoquée dans deux directions distinctes dans ces deux types de contrat : un premier qualitatif **qui insiste sur le temps d'exécution de la prestation : un certain temps ou un trait de temps** ; le second plus quantitatif qui **se fonde sur l'exécution d'une prestation unique ou de prestations échelonnées dans le temps**
- Le législateur a dans l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 opté pour le critère quantitatif en fixant à l'art. 1111-1, al.1 du Code civil : ***« le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique »***, peu importe le temps que puisse prendre la réalisation de cette prestation unique. Exonéré de toute considération temporelle, il faut que toutes les obligations engendrées par le contrat puissent être réalisées en une prestation unique. Au cas ou au moins une des obligations nécessite plusieurs prestations échelonnées dans le temps le contrat est de facto considéré comme à exécution successive
- « ***Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations, d'au moins une partie, s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps » Art. 1111-1 du Code civ.***
- Cette distinction demeure purement formelle et n'a d'intérêt que dans le cadre de la résolution du contrat. Ainsi la résolution d'un contrat à exécution successive ne vaudrait en principe que pour l'avenir ou tout au moins pour la période pendant laquelle le contrat à, par le passé, été régulièrement exécuté
- A noter également que pour les contrats à exécution successive la loi n'a pas autorisé la mention de la fixation unilatérale du prix (prévue uniquement pour les contrats cadres et pour les contrats de prestation de service (C. civ. art. 1164 et 1165)

La classification selon la durée du contrat : Contrats à durée déterminée et indéterminée (IV)

- **Les contrats à durée déterminée** sont des contrats pour lesquels il existe une limite temporelle, ou un objet dont la durée est par avance limitée et fixée dés la conclusion, fixée par la loi ou par les parties, au-delà de laquelle la relation contractuelle cessera de plein droit. Le contrat doit normalement être exécuté fidèlement par les parties jusqu'à son terme
- **Les contrats à durée indéterminée** sont censés être exécutés tant qu'il n'y a pas été mis fin par l'une des parties. L'intérêt de la distinction réside dans la faculté de résiliation unilatérale que possède chaque partie dans un contrat à durée indéterminée.
- La prohibition des engagements perpétuels commande que les contractants puissent de dégager de la relation contractuelle à tout moment pourvu qu'ils respectent un délai de préavis minimal.
- Ce principe auquel a été reconnu une valeur constitutionnelle par le biais de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen figure dans le Code civil.

MERCI

UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC

tétras

CSM HAUTE-SAVOIE